

Pubblicato il 22/12/2023

N. 03843/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00077/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 77 del 2022, proposto da
Damir s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e
difesa dagli avvocati Sonia Cirella, Giuseppe Mazzearella, Alessandro
Maggio, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero
della Giustizia;

contro

Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Cannarozzo Fazzari, con
domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della
Giustizia;

per l'annullamento

a) del bando con il quale il Comune di Palermo ha indetto la procedura
aperta per l'assegnazione delle superfici pubblicitarie sul suolo pubblico
suddiviso in 14 macro-lotti, in applicazione dell'art. 53 del "Regolamento sul
Canone Patrimoniale di concessione del suolo pubblico e di autorizzazione o esposizione

pubblicitaria” e dell’art. 43 del Regolamento sulla Pubblicità e sulle Pubbliche Affissioni;

b) di tutti gli elaborati allegati al predetto bando, con particolare (ma non esclusivo) riferimento al Capitolato, alla Relazione Tecnica e alla “Relazione per Assessore” del 22.11.2021;

di ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto, consequenziale e/o connesso, e comunque lesivo dei diritti ed interessi della ricorrente, con particolare riferimento, ove occorra, alle determinazioni dirigenziali n. 12431 del 24.11.2021 e n. 12794 del 1.12.2021, alla delibera C.C. n. 93 dell’8.10.2015, così come modificata ed integrata dalle deliberazioni C.C. n. 35 del 15.10.2020 e n. 244 del 28.7.2021, al regolamento CUP in parte qua (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 244 del 28.07.2021), nonché al regolamento sulla pubblicità e relativi allegati, in parte qua, e al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e relativi allegati, *in parte qua*, approvati con deliberazione C.C. 8.10.2015, n. 93, come da ultimo modificata dalla deliberazione C.C.35/2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2023 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l’atto introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato e depositato, la società ricorrente ha impugnato il bando in epigrafe indicato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare.

Si è costituito per resistere al ricorso il Comune di Palermo.

Con ordinanza n. 90/2022, la domanda cautelare è stata accolta.

Alla pubblica udienza del 9 ottobre 2023, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso non è fondato, per le ragioni di seguito esposte.

Con il primo motivo di ricorso, Damir s.r.l. ha denunciato la violazione dei principi di trasparenza e di parità di trattamento che deriverebbe dalla mancata disponibilità, al *link* cui rinvia l'art. 3.3 del capitolato di gara (a mente del quale *“Le posizioni dettagliate dei singoli lotti e ogni altra informazione utile sono contenute negli allegati alla deliberazione di C.C. n. 35 del 14.5.2020, reperibile sul sito istituzionale del Comune di Palermo all’indirizzo: ...”*) di alcuni dei documenti ivi indicati.

Tale indisponibilità determinerebbe il rischio di dubbi ed errori, oltre a quello di avvantaggiare coloro che conoscano già, a prescindere dalla legge di gara, la normativa regolamentare di cui si discute e posseggano già una copia di tutto, oppure coloro che sappiano dove andare a ricercare quanto di loro interesse sul sito *web* dell'ente.

Il motivo, prima ancora che infondato, è inammissibile.

In disparte la circostanza che parte ricorrente non ha dedotto l'irreperibilità dei documenti in questione sul sito dell'ente o presso gli uffici del medesimo, ma semplicemente la loro indisponibilità sul *link* indicato – circostanza, questa, che non può di certo costituire un vizio di legittimità del bando - va rilevato che Damir s.r.l. non ha in alcun modo chiarito in che modo tale vizio abbia leso il suo interesse.

Diversamente sarebbe stato ove fosse stato dedotto e provato che i documenti in questione fossero risultati assolutamente indisponibili e che tale circostanza avesse impedito di formulare un'offerta.

Non merita condivisione il secondo mezzo all'esame, con il quale è stata contestata la concreta possibilità di partecipare alla gara con un'offerta remunerativa, come risulterebbe dalla relazione tecnica di parte prodotta

agli atti nonché dalle seguenti circostanze:

- i concorrenti non sarebbero stati messi nelle condizioni di sapere (se non all'esito della valutazione del progetto di localizzazione, rimessa ai tecnici comunali successivamente all'aggiudicazione) se gli impianti commerciali proposti verranno o meno (in tutto o in parte) concretamente installati su suolo pubblico;
- il Comune, nel determinare la base d'asta, avrebbe tenuto conto, per tutti i macro-lotti, anche delle tariffe (più elevate) previste per i poster di più grandi dimensioni (sebbene questi ultimi non siano collocabili nelle zone rosse e arancioni), nonché di quelle relative agli impianti illuminati e luminosi, la cui installazione non è imposta ai concorrenti, con l'effetto ultimo di rendere non remunerativa la concessione.

Quanto rilievo relativo alla mancanza di una prevedibilità certa del numero di impianti pubblicitari che si potranno installare, il collegio rileva che la previsione, contenuta nel bando, di una fase di valutazione, da parte dell'amministrazione, ed eventuale rimodulazione del progetto di localizzazione degli impianti pubblicitari – inevitabile, a fronte dell'utilizzo di suolo pubblico – non può dirsi irragionevole o contrastante con il principio di buona amministrazione.

In un caso analogo al presente, invero, si è ritenuto: *“la circostanza che l'aggiudicatario non ha alcuna certezza di poter installare il numero massimo ivi previsto” e di “ottenere i nulla osta e le autorizzazioni” concerne, per un verso, l'alea insita in tutte le procedure di gara, per altro verso, il legittimo limite rinveniente dall'ordinamento vigente all'esercizio delle connesse attività”* (Cons. Stato, sez. V, 24 febbraio 2020, n.1374).

Né può pretendersi che non si tenga conto delle tariffe relative agli impianti luminosi, la cui installazione è consentita ai futuri concessionari, sebbene non imposta.

Quanto, più in generale, alla sostenuta non remuneratività della

concessione, in primo luogo, deve dubitarsi che i principi a tal proposito resi in materia di appalti pubblici siano immediatamente trasponibili all'ambito della concessione di suolo pubblico, stante la (nettamente) diversa natura del rapporto.

A tal proposito, va rimarcato che la procedura in questione non è tesa all'individuazione del migliore operatore economico (*recte*, della migliore offerta) cui affidare un servizio pubblico; piuttosto, si tratta di una procedura volta all'individuazione di un equo criterio di assegnazione in concessione di spazi pubblici contingentati.

L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, sulla natura e gli scopi delle procedure quale è quella all'esame, ha così chiarito:

“In fatto la collocazione degli impianti pubblicitari commerciali su aree pubbliche urbane, che qui interessa, è vincolata dalla naturale limitatezza degli spazi disponibili all'interno del territorio comunale, ulteriormente ristretta per effetto dei vincoli sia di viabilità sia di tutela dei beni culturali gravanti sul territorio. Ciò motiva la statuizione di cui all'art. 3, comma 3, del citato d.lgs. n. 507 del 1993, per cui ciascun Comune “deve” determinare, oltre la tipologia, anche “la quantità” degli impianti pubblicitari e approvare un “piano generale degli impianti”, con la delimitazione della superficie espositiva massima dei diversi tipi di impianti (nella prassi ripartita tra le zone del territorio urbano), definendosi con ciò un mercato contingentato.

La normativa sulla installazione degli impianti a tutela della sicurezza stradale, e dei valori culturali, si raccorda così a quella ulteriore basata sul presupposto, necessitato e condizionante, del contingentamento dell'attività in questione poiché comportante l'uso di una risorsa pubblica scarsa qual è il suolo pubblico.

Si configura con ciò un rapporto tra l'ente locale e il privato il cui modello di riferimento, alla luce della sua qualificazione sostanziale, è quello concessorio “atteso che è giustappunto una concessione di area pubblica il provvedimento iniziale che conforma il rapporto” (Cons. Stato, n. 529 del 2009 citata), potendo disciplinare il regolamento comunale anche “le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione” (art. 3,

comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993), conflueno nel quadro di tale rapporto, di conseguenza, la regolazione unitaria dei profili di tutela della sicurezza stradale e dei valori culturali.

Ciò rilevato ritiene l'adunanza plenaria che sia corretto allocare l'uso degli spazi pubblici contingentati con gara, dovendosi altrimenti ricorrere all'unico criterio alternativo dell'ordine cronologico di presentazione delle domande accoglibili, che è di certo meno idoneo ad assicurare l'interesse pubblico all'uso più efficiente del suolo pubblico e quello dei privati al confronto concorrenziale.

Il procedimento di gara non contrasta infatti con la libera espressione dell'attività imprenditoriale di cui si tratta, considerato, in linea generale, che la procedura ad evidenza pubblica è istituto tipico di garanzia della concorrenza nell'esercizio dell'attività economica privata incidente sull'uso di risorse pubbliche e che, in particolare, la concessione tramite gara dell'uso di beni pubblici per l'esercizio di attività economiche private è istituto previsto nell'ordinamento, essendo perciò fondata la qualificazione della gara come strumento per assicurare il principio costituzionale della libera iniziativa economica anche nell'accesso al mercato degli spazi per la pubblicità (Cons. Stato, V, n. 529 del 2009, cit; cfr. anche VI, 9 febbraio 2011, n. 894)" (così Cons. Stato, Ad. plen., n. 5/2013).

Ciò premesso quanto alla natura della procedura e ritenuto, dunque, che non possa porsi una questione di necessaria remuneratività del rapporto concessorio, va comunque osservato che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, *"l'impugnazione immediata del bando perché esso non consentirebbe di formulare un'offerta remunerativa ha carattere eccezionale, e come tale richiede una dimostrazione rigorosa dei relativi presupposti"* (tra le tante, Consiglio di Stato sez. IV, 17 luglio 2023, n. 6948).

Nel caso in esame, la dimostrazione della non remuneratività del rapporto si fonda sul presupposto, del tutto indimostrato, che i prezzi di vendita degli spazi pubblicitari al pubblico non possano modificarsi (si confronti la relazione tecnica di parte).

Tale assunto di fondo non può tuttavia condividersi, per l'evidente rilievo che si tratta di prezzi non imposti, ma rimessi al libero mercato e non è affatto dimostrato che quest'ultimo reagirebbe negativamente ad un aumento dei prezzi di vendita.

Con la successiva censura, parte ricorrente si duole della ritenuta irragionevolezza della scelta del criterio dell'offerta al rialzo.

Secondo parte ricorrente, tale criterio non consentirebbe di valorizzare la migliore qualità degli impianti pubblicitari che alcuni operatori economici potrebbero voler realizzare.

Il motivo non è fondato, in considerazione della natura della procedura all'esame, di cui si è detto.

È evidente, infatti, che fine primario dell'amministrazione non è quello di garantire il miglior servizio alla comunità, posto che non si tratta di affidare in concessione un pubblico servizio, quanto, piuttosto, di selezionare, con un criterio equo, gli operatori economici cui assegnare in concessione beni pubblici a disponibilità limitata. Né può dirsi incompatibile con la detta natura della procedura il fine – del tutto conforme all'interesse pubblico – di trarre dalle concessioni che si andranno a stipulare il canone più alto, tra quelli offerti dagli operatori economici, al fine di rendere maggiormente proficuo lo sfruttamento del suolo pubblico.

Si noti, peraltro, che il quesito posto al vaglio dell'Adunanza plenaria – da questa risolto in senso positivo – nel precedente menzionato, riguardava proprio la legittimità dell'indizione di un'asta con offerta economica al rialzo per l'assegnazione degli spazi pubblici disponibili per gli impianti pubblicitari.

È infondato il successivo motivo di ricorso, ove è criticata la scelta dell'amministrazione di: (i) non individuare previamente i siti di installazione; (ii) non stabilire nulla sulla qualità (anche strutturale) degli impianti; (iii) far sì che ciascun imprenditore aggiudicatario potesse avviare

l'attività pubblicitaria utilizzando il 70% degli impianti, con riserve della P.A. sul restante 30%, ma a canone invariato.

La censura all'esame – che costituisce un'esplicitazione, sotto taluni profili, delle censure già proposte (attinenti la scarsa remuneratività della gara, la prevista valutazione da parte dell'amministrazione del progetto presentato dalle concorrenti, la previsione dell'unico criterio del massimo rialzo) - è infondata per le ragioni già esposte in sede di esame dei detti motivi.

Quanto all'assenza di previsioni sulla qualità degli impianti, si tratta di censura analoga a quella resa sub V.f, al cui esame si rinvia.

Parte ricorrente ha, poi, dedotto una serie di vizi propri del *“Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria”*, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 244/2021, ritenendo che i medesimi incidano, in via derivata, sulla legittimità dell'impugnato bando.

Anche tali doglianze non sono meritevoli di accoglimento.

Con i motivi sub V.a e V.m, la società ricorrente sostiene che la determinazione del canone, come effettuata nel regolamento, contrasterebbe con la previsione di cui al comma 820 dell'art. 1 l. 160/19, per il quale: *“L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma”*.

Il richiamato comma 819 così stabilisce:

“Il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico;*
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”*.

Tali previsioni sarebbero state violate dall'art. 29 del regolamento CUP, il quale stabilisce che *“gli impianti pubblicitari installati sul bene appartenente all'Ente sono assoggettati al pagamento del canone determinato dalla somma della corrispondente voce tariffaria per esposizione pubblicitaria (tabella C) con quella prevista per l'occupazione del suolo (tabella B) sempre in funzione della superficie del periodo autorizzati”*.

La previsione contestata, a ben vedere, non stabilisce che i due canoni (quello per l'occupazione di suolo pubblico e quello per la diffusione di messaggi pubblicitari) si debbano contestualmente applicare.

Piuttosto - ai fini della quantificazione del canone pubblicitario applicabile alle ipotesi in cui il mezzo pubblicitario non appartenga ad un soggetto privato o ad altro soggetto pubblico, ma allo stesso Comune – prevede la somma di due voci tariffarie (quella relativa all'occupazione di suolo pubblico e quella inerente la diffusione di messaggi pubblicitari).

Tale previsione costituisce applicazione dei commi 816 e 817 del medesimo articolo di legge, per i quali il canone unico in discussione sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, ed *“è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*.

Con i motivi di cui ai punti V.b, V.c, V.d , V.f e V.l del ricorso, parte ricorrente ha sostenuto che il regolamento sarebbe illegittimo, per contrasto con l'art. 1, co. 821 della legge 160/19 e con l'art. 3 del d.lgs. 507/1993 e ciò in quanto sarebbe privo del contenuto minimo previsto dalle menzionate disposizioni.

Segnatamente, il regolamento illegittimamente ometterebbe di:

- indicare l'accorpamento dei lotti che saranno messi a bando;

- prevedere l'esatta ubicazione di ciascun impianto, previa verifica di compatibilità con le norme del codice della strada (d.lgs. n. 295/92) e con quelle di cui al codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42/04) e previa acquisizione del parere della Soprintendenza;
- prevedere le caratteristiche di qualità degli impianti pubblicitari, in violazione della disciplina sulle pubbliche forniture, sul collaudo delle opere pubbliche da parte del committente, sull'anomalia delle offerte.

In realtà, la disciplina invocata da parte ricorrente non prevede affatto tali previsioni nell'ambito del contenuto che il regolamento sul canone unico deve necessariamente avere.

L'art. 1 l. 160/2019 (e, in termini analoghi, l'art. 3, co. 3 d.lgs. 507/93), invero, così stabilisce:

“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando*

permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

Quanto agli impianti, dunque, è sufficiente che siano previste le tipologie di impianti autorizzabili e di quelli vietati, nonché il numero massimo di impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie.

In particolare, non è prevista la necessità di indicare le caratteristiche qualitative e tecniche minime, né tali previsioni sono indirettamente imposte dai principi in materia di pubbliche forniture, invocati in ricorso, posto che, come si è detto, la procedura in esame ha tutt'altra natura.

Sono inammissibili per carenza di interesse i motivi di cui ai punti V.e, V.g, V.h, con i quali la società ricorrente ha censurato:

- l'art. 47 del regolamento del 2015, che consente che al regime concessorio si affianchi la possibilità, per l'aggiudicataria, di avanzare singole richieste autorizzative per l'ipotesi in cui dovessero residuare superfici da coprire con nuovi impianti;

- gli allegati tecnici al PGIP, laddove contengono la previsione di accorpamento dei lotti in

14 macro-lotti da mettere a gara, senza chiarire le ragioni di tale quantificazione dei macro-lotti;

- gli artt. 2, 3 e 53 del regolamento oggi impugnato, laddove sono richiamati quattro regolamenti, che dovrebbero essere soggetti ad abrogazione a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina.

Le censure sono prive del necessario interesse all'impugnazione, atteso che

la ricorrente non chiarisce in che modo tali previsioni possano ledere il suo interesse.

Non può, invero, ritenersi che qualsivoglia disposizione regolamentare che appaia imprecisa o non sufficientemente motivata possa ritenersi illegittima, tanto più se non emerga in che modo i vizi denunciati possano ripercuotersi negativamente sulla sfera di interesse del ricorrente.

È infondato, ancora, il motivo sub V.i, con cui è stata denunciata la violazione dell'art. 23 del codice della strada, che prevede: *“il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante”*.

La disposizione in esame, invero, fa riferimento al regolamento esecutivo del codice della strada (d.lgs. 285/1992) e non al regolamento comunale previsto dal successivo d.lgs. 507/1993.

In conclusione, il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidandole in € 3.500,00, oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2023, con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente

Raffaella Sara Russo, Primo Referendario, Estensore

Bartolo Salone, Referendario

L'ESTENSORE
Raffaella Sara Russo

IL PRESIDENTE
Guglielmo Passarelli Di Napoli

IL SEGRETARIO